Universidad de Buenos Aires

Facultad de Derecho

Derecho de la Integración

Autonomía de la voluntad en los contratos internacionales

Teorías, autonomía material y conflictual, y sus límites

Estudiar con constancia es la mejor manera de convertir los conceptos en conocimiento.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de "Derecho de la Integración" no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Contents

Chapter 1

Autonomía de la voluntad: concepto y teorías

1.1 Normas imperativas y normas dispositivas

La autonomía de la voluntad no puede desplazar a las normas **imperativas** o **coactivas**. Opera solamente en un ámbito de cuestiones donde las normas se consideran **supletorias** de la voluntad de las partes.

Definición: Normas dispositivas y normas imperativas

Las normas **dispositivas** (o supletorias) *disponen, pero no obligan*: las partes pueden apartarse de ellas y hacer otra cosa. Las normas **imperativas** o **coactivas**, en cambio, no pueden ser desplazadas por la autonomía de la voluntad.

Los negocios y los contratos se encuentran normalmente en el ámbito de las normas dispositivas. Todos los sistemas jurídicos tienen normativa sobre contrato de transporte, contrato de seguro, contrato de compraventa internacional de mercaderías y contrato de alquiler; sin embargo, otorgan a las partes un ámbito para modificar esas cuestiones. Las partes pueden dejar de lado determinadas cuestiones establecidas por la ley.

1.2 La postura que niega la autonomía de la voluntad

En la posición totalmente enfrentada a la de quienes sostenían que la autonomía era absoluta —algunos afirmaban que "venía de Dios"— se encuentra un sector de la doctrina que sostiene que la autonomía de la voluntad, en realidad, **no existe**.

El razonamiento es el siguiente. Si la autonomía de la voluntad queda determinada por la existencia de normas facultativas o dispositivas, las partes pueden ejercer su libertad de acción y su libertad contractual únicamente mientras se mantengan en ese ámbito. Si la persona es libre porque el legislador le permite hacer determinada cosa, entonces el

ámbito de su autonomía y de su libre determinación depende de lo que dispone otro, y la determinación en realidad "no es tuya": el otro está permitiendo hacerlo. De allí concluyen que la autonomía de la voluntad no existe como tal.

Lo que existe es el principio de **libertad de contratación**, y el ámbito en el que esta puede desarrollarse **deriva de la ley**.

Importante

Se mencionan tres teorías porque, según la teoría que adopte cada Estado, se examinan los fundamentos y la extensión que este otorga a la autonomía de la voluntad.

1.3 Las teorías y su evolución histórica

Las distintas posiciones no son solamente tres teorías: coinciden, además, con determinadas etapas de evolución. Cuando surgió la *lex mercatoria* existía autonomía absoluta. Como referencia literaria de esa concepción se menciona *El mercader de Venecia*, de Shakespeare, lo que indica que no se trataba de una idea extraña.

Esta coincidencia con un desarrollo histórico responde, ya sea a una convicción jurídica, ya sea a una conveniencia de los negocios, que lleva a adoptar o modificar las teorías. Hoy, doctrinariamente, por más que un país declare adoptar o no la autonomía de la voluntad, **nadie niega** de modo tajante la noción de autonomía de la voluntad. Se habla de autonomía de la voluntad y no de libertad de contratación.

Table 1.1: Las posiciones sobre la autonomía de la voluntad (ordenado a partir de lo dicho en clase)

Posición	Qué sostiene	Fundamento	Etapa / observación
Autonomía absoluta	Las partes pueden pactar sin límites; lo pactado rige tal cual.	Algunos decían que "venía de Dios".	Se asocia a la *lex mercatoria*; ejemplo literario: *El mercader de Venecia*.
Negación de la autonomía	No existe autonomía; solo existe libertad de contratación.	La libertad se ejerce en el ámbito que el legislador permite (normas dispositivas).	Grupo de la doctrina "totalmente enfrentado" a la postura absoluta.
Autonomía limitada (actual)	Existe autonomía de la voluntad, pero con límites.	Nadie niega hoy la noción; se habla de autonomía de la voluntad y no de libertad de contratación.	Posición actual: límites en las estipulaciones y en la ley que se puede elegir.

Nota

El cuadro ordena las posiciones mencionadas en la clase. La explicación inicial de la primera teoría quedó fuera de la grabación.

1.4 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué diferencia hay entre norma imperativa y norma dispositiva?	Las imperativas (coactivas) no pueden ser desplazadas por la autonomía de la voluntad. Las dispositivas (supletorias) "disponen, no te obligan": las partes pueden dejarlas de lado. Los negocios y contratos se mueven normalmente en este segundo ámbito.
¿Qué sostiene la postura que niega la autonomía de la voluntad?	Que, si la libertad de las partes depende de lo que el legislador les permite, la determinación "no es tuya". Lo que existe es el principio de libertad de contratación, cuyo ámbito deriva de la ley.
¿Para qué importa conocer las teorías?	Porque, según la teoría que adopte un Estado, se examinan los fundamentos y la extensión que da a la autonomía de la voluntad. Además, las teorías coinciden con etapas históricas (*lex mercatoria*, autonomía absoluta; hoy, autonomía limitada).
¿Qué postura rige hoy?	Nadie niega la noción de autonomía de la voluntad, aunque limitada. Se habla de autonomía de la voluntad y no de libertad de contratación.
Resumen: las normas dispositivas permiten a las partes apartarse de la ley y las imperativas no; en ese ámbito supletorio se mueven los contratos. Una posición doctrinaria niega la autonomía y la reduce a libertad de contratación derivada de la ley; las teorías acompañan etapas históricas, desde la autonomía absoluta de la *lex mercatoria* hasta la actual autonomía limitada.	

Chapter 2

Autonomía material y autonomía conflictual

2.1 Autonomía material

La autonomía material es la libertad de contratación: las estipulaciones insertas en el contrato son, para las partes, una regla a la que deben someterse como a la ley misma. Brasil, por ejemplo, acepta la autonomía material. Esa idea corresponde a la formulación de Vélez Sarsfield.

Fórmula / Regla: Art. 1197 del Código Civil de Vélez Sarsfield (derogado)

«Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y no pueden ser revocadas sino por mutuo consentimiento o por las causas que la ley autoriza.»

Norma aludida en la clase. Texto del Código Civil de la Nación vigente hasta 2015.

Fórmula / Regla: Art. 959 del Código Civil y Comercial de la Nación (norma vigente concordante)

«Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes o en los supuestos en que la ley lo prevé.»

Agregado del apunte original: no fue mencionado en la clase, pero es la norma que hoy recoge la misma idea.

Casi todos los ordenamientos jurídicos autorizan a las partes a celebrar contratos y establecen que sus obligaciones quedarán reguladas en la medida en que lo hayan establecido en ellos.

Ejemplo: Qué día se entrega, qué precio se paga

¿Qué día está obligada a entregar la mercadería una de las partes? El día fijado en el contrato; eso es obligatorio para ella. ¿Qué precio debe pagar? Lo que se puso en el contrato. Esas estipulaciones son obligatorias. Eso es **autonomía material**, lo que otros llaman libertad de contratación.

Para quienes niegan la autonomía, esto no es autonomía, porque la autonomía *per se* no existe. Hoy se sostiene que la autonomía de la voluntad existe, pero limitada. Existirán determinados límites, tanto en cuanto a las estipulaciones que se incluyen en el contrato —qué se puede pactar y qué no— como en cuanto a la ley que puede elegirse para regular ese contrato. Esto último es la autonomía conflictual.

2.2 Autonomía conflictual

Las cláusulas que las partes incluyen en el contrato constituyen la autonomía material. En cambio, si en el contrato se pacta, por ejemplo: «El presente contrato, los derechos y obligaciones, responsabilidades, la interpretación de sus cláusulas y demás, será regido por la ley uruguaya», las partes establecieron qué ley dirá si lo que hicieron en el contrato está bien.

Se podía celebrar ese contrato de compraventa: el objeto era lícito, el precio era excesivo, el interés era usurario. Conforme a la ley que va a regular si esas estipulaciones son válidas, y la interpretación de ellas, ya no se trata de una autonomía absoluta.

Ejemplo: El mercader de Venecia

Si se pactó la entrega de una parte del corazón, debe cumplirse. La objeción de que ello viola el orden público no tuvo lugar: no se habló de orden público ni se accedió a esas soluciones. El caso se resolvió conforme a los mismos términos del contrato.

Table 2.1: Autonomía material y autonomía conflictual

	Autonomía material	**Autonomía conflictual**
Qué es	Libertad de fijar el contenido del contrato: las cláusulas.	Posibilidad de elegir la ley que regirá el contrato.
Otro nombre	Libertad de contratación.	—
Ejemplo de la clase	Fecha de entrega y precio fijados en el contrato.	«Este contrato será regido por la ley uruguaya».
Aceptación	Todos la aceptan.	Va «a otro nivel»: ningún Estado la admite de manera absoluta.
Límites	Qué se puede pactar y qué no (p. ej., orden público).	La ley elegida puede ser desplazada si afecta principios fundamentales del Estado.

2.3 Qué ley rige cada aspecto del contrato

Hay tres cuestiones distintas, cada una regida por su ley. En primer lugar, la **celebración del contrato**: oferta, demanda, momento y lugar de celebración; esto determina si existe contrato. En segundo lugar, otra ley regula la **validez extrínseca**, es decir, las formalidades del acto. En tercer lugar, otra normativa determina si el contrato es **sustancialmente válido**.

Superadas la celebración y las formalidades, corresponde examinar el objeto. Aunque el contrato se haya hecho por escribano público y tenga oferta y precio, puede ocurrir que el objeto no estuviera a la venta, que no fuera susceptible de comercialización (se da como ejemplo la venta del Obelisco) o que se tratara de un contrato de compraventa internacional de marihuana.

Table 2.2: Las tres cuestiones del contrato y su ley

Cuestión	**Qué determina**	**Ejemplo de la clase**
Celebración del contrato	Si el contrato existe: oferta, demanda, momento y lugar de celebración.	Hubo oferta, hubo precio.
Validez extrínseca (formal)	Las formalidades del acto.	El contrato se hizo por escribano público.
Validez sustancial	Si el contrato es sustancialmente válido: objeto, precio, interés.	El objeto no era susceptible de comercialización (el Obelisco; la marihuana).

Ejemplo: Compraventa internacional de marihuana, ley uruguaya y juez argentino

Se celebra un contrato de compraventa con Uruguay, formalmente escrito, y se designa como ley aplicable la ley uruguaya. La ley uruguaya permite la compraventa de marihuana para consumo personal. El juez uruguayo que aplique su ley considerará válido el contrato: hubo autonomía de la voluntad de las partes y, mientras sea para uso personal y por la cantidad adquirida, no hay problema.
Si el juez es argentino, al ir a aplicar la ley uruguaya dirá que ello va contra el orden público argentino, porque el objeto es ilícito. No aplicará la ley uruguaya y declarará que esa elección de ley no es válida. La razón es que la elección de la ley aplicable hecha por autonomía de la voluntad tiene ciertos límites: no se puede hacer cualquier cosa ni elegir cualquier ley.

Más allá de las estipulaciones del contrato, es necesario saber qué ley analizará si el contrato es ejecutable o no. Cuando se afirma que una cláusula es nula, se la está juzgando conforme a una determinada ley; de ahí la pregunta por la ley aplicable al contrato.

Si se parte de que el Estado adopta la autonomía conflictual, es decir, la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable, ningún Estado la adopta de manera absoluta ("elijo la ley que quiero"). Quienes aceptan la autonomía conflictual establecen normalmente algunos límites. El primero es el orden público: si la ley elegida va contra el orden público del Estado, no se aplica.

Importante

Más allá de las cláusulas, hace falta saber qué ley va a juzgar si el contrato es válido y ejecutable. Un mismo contrato puede ser válido para el juez uruguayo y no ser reconocido por el juez argentino, porque la elección de la ley tiene límites: ninguna ley elegida se aplica si va contra el orden público del Estado del juez.

2.4 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es la autonomía material?	La libertad de fijar las cláusulas del contrato (fecha de entrega, precio). Lo estipulado obliga a las partes como la ley misma (art. 1197 del Código Civil derogado; hoy, art. 959 CCCN, según el agregado del apunte). Otros la llaman libertad de contratación.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es la autonomía conflictual?	La posibilidad de que las partes elijan la ley que regirá el contrato, su validez y la interpretación de sus cláusulas (por ejemplo: «será regido por la ley uruguaya»). Ningún Estado la admite de forma absoluta.
¿Qué leyes intervienen en un contrato?	Una regula la celebración (oferta, demanda, momento y lugar); otra la validez extrínseca (formalidades); otra la validez sustancial (objeto, precio, interés).
¿Qué pasa con el contrato de compraventa de marihuana con ley uruguaya?	El juez uruguayo, aplicando su ley, lo considera válido. El juez argentino no aplica la ley elegida porque va contra el orden público argentino: objeto ilícito. La elección de ley tiene límites.
Resumen: la autonomía material consiste en fijar las cláusulas del contrato, y todos la aceptan; la autonomía conflictual consiste en elegir la ley aplicable y ningún Estado la admite de manera absoluta. Un mismo contrato, como la compraventa de marihuana regida por ley uruguaya, puede ser válido para un juez y no ser reconocido por otro, porque la elección de ley tiene límites, el primero de ellos el orden público.	

Chapter 3

Límites: orden público y normas de policía

3.1 El orden público como límite

Los límites más habituales que aparecen en los distintos ordenamientos jurídicos a la autonomía de la voluntad conflictual —es decir, a la posibilidad de elegir la ley aplicable— incluyen el **orden público**.

Definición: Orden público

Es algo tan importante para el Estado que no admite la autonomía de la voluntad de las partes y puede frenar la aplicación del derecho extranjero. Si lo pactado, o el resultado de aplicar la ley elegida, afecta principios fundamentales del Estado, no se reconoce.

Cuando se verifica que el acto conculca esos principios fundamentales, no se aplica ni la autonomía material ni la autonomía conflictual. Se distingue entre orden público interno y orden público internacional.

Como ejemplo se mencionó el matrimonio de tres personas, permitido en algunos países: nuestro orden público no lo aceptaría. Distinto es el caso de la compraventa de marihuana, que se plantea en materia de negocios: aquí hay un delito, y aunque algunos sostengan que para consumo está autorizado, la cuestión exige analizar lo que se expone a continuación.

3.2 Artículo 19 y consumo personal

Se sostiene que la Corte autorizó el consumo en el famoso fallo "para consumo personal". Esa es una interpretación muy libre, propia de quienes leyeron superficialmente el fallo: **la Corte no lo autorizó**. La Corte señaló que hay principios, y uno de ellos es la libertad, consagrada en el artículo 19.

Fórmula / Regla: Art. 19 de la Constitución de la Nación Argentina

«Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.»

La docente lo cita de memoria; el apunte original transcribe el texto constitucional.

Ejemplo: La Corte y la tenencia para consumo personal

Se trata de situaciones en las que se detiene a determinados jóvenes, en circunstancias sospechosas, se les revisan los bolsillos y se les encuentra droga. Es algo interno de la persona, como si se allanara una casa y se encontrara un cigarrillo de marihuana en la mesita de luz. La Corte dijo que, si es para consumo personal, la violación del derecho a la intimidad y a las acciones personales es demasiado grave para combatir un delito tan menor.

Si en cambio se consume en la vía pública, la policía no está invadiendo el ámbito de intimidad. No se priva de la intimidad a quien lo hace públicamente, y puede ser detenido. Lo que la Corte dijo es que no era posible, para perseguir el delito de consumo, invadir ámbitos privados: ni el domicilio ni la intimidad personal; no se puede abrir la mochila. Distinta es la situación si se sospecha que en esa casa hay venta: en ese caso se puede allanar, y hay que pedir la orden.

La política de la ley anterior para combatir el delito era perseguirlo en todos los grados y en todas las instancias. Después de 10 años de vigencia de la norma, se advirtió que se estaba procesando a consumidores, a personas que a veces están enfermas y son consumidores porque ya tienen una adicción, y que el tráfico no había disminuido. Se estaba atacando al eslabón débil, sin producir el beneficio que la sociedad necesita. El delito sigue siendo delito; la Corte dijo que se busque combatirlo por otro lado. La premisa utilizada era que no habría tráfico si no hubiera consumo, y esa hipótesis no dio resultado.

En conclusión, la Corte no autorizó la invasión de la propiedad o de la intimidad cuando el delito perseguido era el consumo. En la Argentina no está permitido el consumo: puede hacerse si no se es descubierto.

Nota

La docente no menciona el nombre del fallo; el apunte original indica que se trata de la doctrina de la Corte Suprema sobre tenencia para consumo personal y el art. 19 de la Constitución («Arriola», 2009).

En Uruguay, en cambio, el consumo personal está permitido; también en Países Bajos. Si las partes eligen esa ley, el juez que la aplique considerará que el contrato es válido, aunque el vendedor haya sido argentino, y lo hará ejecutable (por ejemplo, para reclamar el cumplimiento si no se entregó o por la calidad de lo entregado). La República Argentina no podría hacerlo bajo ninguna circunstancia, aunque se haya hecho uso de la autonomía de la voluntad y se haya elegido una ley aplicable: no puede aplicar esa ley por el principio

del orden público, porque la persecución de un delito limita la autonomía de la voluntad de las partes.

Existe entonces la autonomía material, con la que todos están de acuerdo, y la autonomía conflictual, que va a otro nivel: elegir la ley que juzgará las disposiciones del contrato.

3.3 Normas de policía y normas coactivas

Existe la autonomía con ciertos límites. La **norma de policía** es parecida al orden público, pero más rígida. El orden público afecta principios fundamentales de la legislación: su espíritu, no su letra. Con el orden público se hace un camino de ida y vuelta: se mira el derecho extranjero y se lo confronta con el propio ordenamiento para ver si hay una confrontación.

Definición: Norma de policía

Es una norma de **aplicación inmediata**. A pesar de que exista un elemento de extranjería que vincule la relación jurídica con otros ordenamientos, existen cuestiones que el Estado considera que nunca pueden quedar sometidas a una ley extranjera ni a la autonomía de la voluntad de las partes: son cuestiones de aplicación directa e inmediata, aunque haya elementos de extranjería.

Las normas de policía suelen confundirse con las "normas coactivas". Las normas coactivas son normas obligatorias, y hay muchas normas obligatorias que no son normas de policía. Por ejemplo, el homicidio está prohibido, pero no es una norma de policía: se aplica la ley del lugar de perpetración del delito, y no siempre la ley argentina.

Las normas de policía hacen a la esencia del Estado, con tal importancia e impacto que se necesita algo más fuerte que una norma coactiva, obligatoria o imperativa: algo que se aplique de manera directa y no sea cuestionable. Estas situaciones no son habituales; pueden darse en forma extrema. La idea es: «esto se hace así y punto». Un ejemplo es la pandemia.

Table 3.1: Norma coactiva, orden público y norma de policía

	Norma coactiva / imperativa	**Orden público**	**Norma de policía**
Idea central	Norma obligatoria: no puede ser desplazada por las partes.	Principios fundamentales del ordenamiento («el espíritu», no la letra).	Cuestiones esenciales para el Estado, de aplicación directa e inmediata.
Cómo opera	Se aplica la ley que corresponda (p. ej., homicidio: ley del lugar del delito).	Camino de ida y vuelta: se mira el derecho extranjero y se lo confronta con el propio.	No se confronta: se aplica directamente, aunque haya elementos de extranjería.
Rigidez	Hay muchísimas.	Menos rígido que la norma de policía.	Más rígida que el orden público; situaciones excepcionales y extremas.

Importante

No toda norma coactiva es una norma de policía: «hay un montón de normas obligatorias que no son normas de policía». Las normas de policía se reservan para lo que hace a la esencia del Estado.

3.4 Ejemplo de norma de policía: la pandemia

Ejemplo: La pandemia

La pandemia vulneró muchos derechos: el derecho al trabajo, el derecho a circular. Fue como si cambiaran las reglas del juego: quien tenía un contrato celebrado y debía viajar no podía hacerlo. La ley del lugar de cumplimiento del contrato decía una cosa, pero las soluciones fueron otras: "no viajás, y devuelven la plata" o "no se devuelve nada, porque si no las empresas quiebran". No se estableció sin criterio: la situación era tan extraordinaria que necesitaba una solución específica para ese tema.
Cada Estado dictó sus normas. Todos hablaban de que no se podía transmitir ni contagiar a las personas, pero cada uno lo implementó de una manera distinta.

3.5 Ejemplo de norma de policía: la crisis de 2001 y el corralito

3.5.1 Cómo funcionaba la paridad y por qué faltaban los dólares

Ejemplo: Los depósitos en dólares que no existían

El Estado había fijado la paridad un peso, un dólar: eran equivalentes. Quien depositaba un peso en el banco depositaba el equivalente a un dólar. Quien tenía una cuenta en dólares y depositaba 100, figuraba con 100 dólares depositados, cosa que hacía todo el mundo porque se había equiparado el valor. No era posible depositar pesos y comprar libremente dólares; equivalía al dólar.
Todo el mundo tenía depósitos en dólares sin que hubiera dólares en los bancos: en las cajas había pesos. Si todos iban juntos a retirar sus dólares, no existían.

3.5.2 El corralito y la pesificación de los contratos

A la crisis económica, producto del endeudamiento del Estado, se sumó la decisión de establecer el **corralito financiero**: nadie podía sacar dinero del banco, ni dólares ni pesos. Se autorizaban 200 pesos, por persona, sin importar si la persona era soltera o casada con hijos. Era arbitrario.

Respecto de los contratos pactados en dólares, se dispuso que se pagarían en pesos, a una tasa establecida por el Estado. Primero se habló de un peso con 25 (la docente no recuerda con certeza la cifra) y luego se fijó 1,40. Si en el contrato se había pactado pagar la mercadería 200 dólares, debían pagarse 200 por 1,40 en pesos. Era totalmente arbitrario, porque el valor no estaba fijado por el mercado; no podía dejarse al valor de mercado porque todo el mundo se desesperaría por conseguir dólares, dado que la crisis había depreciado el peso enormemente.

El Estado prohibió sacar dinero de los bancos e informátizó todo: todos los salarios debían pagarse por banco. Antes pasaba el camión de caudales y se pagaba a la gente en la puerta de la oficina; desde entonces se hace por transferencia bancaria. Todo eso surgió porque el dinero era ficticio: no había ni dólares ni pesos en el banco, porque el Estado se había endeudado y había tomado esos pesos. Entonces se declaró el *default*: se dejó de pagar porque ya no había dinero.

3.5.3 Por qué eran normas de policía

Todas las normas dictadas durante ese período se presentaban como normas que afectan el orden público, pero realmente eran **normas de policía**, porque no admitían pacto en contrario ni la aplicación de un derecho extranjero. Si en el contrato se había pactado

que el lugar de pago sería Francia, no podía pagarse en dólares en Francia: se pagaba en pesos, porque no había dólares para transferirlos.

Por eso muchos acudieron a la Corte Internacional y hubo tantos fallos en contra en esa fecha: para ellos la ley de emergencia no importaba; si las partes habían pactado algo, el contrato debía cumplirse en los términos pactados. No importaba que el Estado hubiera considerado ficticiamente que el valor era el mismo: los dólares no existían, y se tenían certificados de depósito que decían que se habían depositado tantos dólares.

La crisis fue de tal envergadura que las normativas se dictaban con enorme frecuencia. Llegó al punto de que una norma prohibió la quiebra de las empresas: no se podían iniciar juicios de quiebra y ningún juez podía decretar una quiebra. En la peor crisis económica del país, en cinco años no quebró ninguna empresa. El motivo era que hacerlo habría agravado el desastre: cierre de empresas, desempleo y otras consecuencias.

Esas disposiciones eran normas de policía que cambiaban los contratos de trabajo, los contratos de compraventa y el contrato de depósito bancario; cambiaban todas las reglas del juego. Frente a la pretensión de que se aplicara la ley vigente al celebrarse el contrato, o de que los contratos se rigieran por otro derecho, la respuesta era que se trataba de una norma de policía y se aplicaba sí o sí.

Importante

Las normas de emergencia de 2001 se presentaban como «de orden público», pero la docente las califica como normas de policía: no admitían pacto en contrario ni aplicación de derecho extranjero. Cambiaron los contratos de trabajo, de compraventa y de depósito bancario, y se aplicaron aunque las partes hubieran elegido otra ley o pactado otro lugar de pago.

3.6 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cómo funciona el orden público?	Frena la aplicación del derecho extranjero (o del pacto) cuando su resultado afecta principios fundamentales del Estado. Se hace un camino de ida y vuelta: se mira el derecho extranjero y se lo confronta con el propio. Hay orden público interno e internacional.
¿Qué dijo la Corte sobre el consumo personal y el art. 19?	No autorizó el consumo: dijo que no se puede invadir el domicilio ni la intimidad para perseguir el delito de consumo. En la vía pública el consumo sigue siendo delito. Para investigar venta sí se puede allanar, con orden.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué es una norma de policía?	Una norma de aplicación inmediata y directa, que el Estado considera esencial y que no admite someterse a ley extranjera ni a la autonomía de la voluntad, aunque haya elementos de extranjería. Es más rígida que el orden público.
¿Toda norma coactiva es una norma de policía?	No. Hay muchas normas obligatorias que no son de policía. Ejemplo: el homicidio está prohibido, pero se aplica la ley del lugar de perpetración del delito.
¿Qué ejemplos de normas de policía dio la docente?	La pandemia (soluciones específicas para contratos de viaje, por ejemplo) y la crisis de 2001: corralito, pesificación de contratos en dólares, informatización de salarios, *default* y prohibición de las quiebras.

Resumen: el orden público frena la ley elegida cuando afecta principios fundamentales del Estado, como ocurre con la compraventa de marihuana, que la Corte no autorizó. Las normas de policía son más rígidas: se aplican de forma directa e inmediata aunque haya elementos de extranjería, y no toda norma coactiva lo es. La pandemia y la crisis de 2001 ilustran su aplicación.

Chapter 4

Protección del débil jurídico

4.1 El débil jurídico como límite

Además del orden público y de las normas de policía, existen otros límites a la voluntad, entre ellos el contrato de consumo: en el derecho argentino no se puede elegir derecho extranjero en el contrato de consumo.

Se lo presenta, en general, como un límite en protección del **débil jurídico**: aquellos casos en que las partes no están en igualdad de negociación, sea contrato de consumo, de trabajo o de seguros. En el seguro se informa cuál es la prima y no hay mucho para negociar; la Superintendencia aprobó la póliza y esa es la que se aplica. La parte no tiene poder de negociación, o este es bastante limitado.

Cuando hay un débil jurídico aparece un límite a la autonomía de la voluntad, pero puede darse de dos maneras distintas. La República Argentina, en materia de contratos de consumo, adoptó la postura de que **no se puede elegir la ley aplicable**. Se interpreta que, sea lo que sea que se elija, lo impone la otra parte: nunca se elegirá lo que más convenga al débil, porque este evalúa otras cosas, otros beneficios, otras circunstancias, y no toma la protección más conveniente. Hay otros sistemas jurídicos que, en cambio, ...

4.2 Débil jurídico y orden público no son lo mismo

Ante la observación de que la normativa de defensa del consumidor se aplica de todos modos por ser de orden público, la docente aclara que la doctrina, y también los legisladores, suelen decir que todas las normas coactivas son de orden público. Hay que distinguir que algo sea **obligatorio** de que sea de **orden público**: son dos cosas distintas. Se actúa de una u otra manera porque algo cuestiona principios fundamentales del sistema jurídico, o porque se cree proteger a la parte más débil.

La tutela de la parte más débil es considerada por algunos de orden público, como el derecho laboral, cuyos principios son importantes. En materia laboral algunas cuestiones

se consideran fundamentales. Para el derecho laboral o el de consumo, tal principio es de orden público, pero eso no significa que todos los contratos de consumo o todas las disposiciones de derecho laboral lo sean.

Cada especialidad considera que su materia es de orden público o de raigambre constitucional, porque el derecho del trabajo o el del consumidor están en la Constitución. Pero eso no significa que la Ley de Contrato de Trabajo tenga nivel constitucional; a eso apunta el razonamiento.

Se prohíbe a las partes elegir la ley aplicable porque se cree proteger a la parte más débil, evitando que elija una ley que le sea perjudicial. Lo mismo ocurre en materia laboral: no se deja establecer libremente la cantidad de horas de trabajo y se pone un límite diario, porque se supone que la necesidad de conseguir el trabajo lleva a aceptar condiciones perjudiciales.

Ejemplo: El trabajador que prefiere dos semanas seguidas

Quizá el trabajador prefiere trabajar dos semanas seguidas sin descanso y luego tomarse los cuatro fines de semana juntos, de modo que, sumado el fin de semana, sean siete días sin trabajar. Si a él le conviene, ¿por qué no? Cuando se dice «no, porque es de orden público», cabe preguntar qué otro principio se está vulnerando si la persona lo hace conscientemente y porque le conviene.
Se tiene presente la Revolución Industrial: se trabajaban 18 horas, con niños de 8 años. Por eso se limita la jornada y se otorgan vacaciones.

La noción de orden público y la protección del débil jurídico son en realidad **dos carriles distintos**. La protección del débil jurídico trata de que este no pacte cosas que le sean perjudiciales.

Table 4.1: Orden público y protección del débil jurídico: dos carriles distintos

	Orden público	**Protección del débil jurídico**
Fundamento	Principios fundamentales de la sociedad y del ordenamiento en general.	Tutelar a la parte más débil: que no pacte cosas que le sean desfavorables.
Pregunta que se hace	¿La ley elegida o el acto conculca principios fundamentales del Estado?	¿Las partes negociaron en igualdad? ¿La elección protege o perjudica al débil?
Ejemplos	Objeto ilícito; moral y buenas costumbres.	Contratos de consumo, de trabajo y de seguro.
Cuidado	No todo lo obligatorio es de orden público.	No se lo debe meter en «la bolsa» del orden público.

4.3 Dos modalidades de protección: prohibir o controlar la ley elegida

El Convenio de Roma, hoy Reglamento de Roma, rige en materia de contratos civiles y comerciales y está vigente en la Unión Europea. Permite la autonomía de la voluntad en materia de contrato de trabajo, de seguro y de consumo, siempre y cuando la ley elegida sea **más favorable y más protectoria** para el consumidor, el trabajador o el asegurado.

Si se pactó una ley y, llegado el juicio, el juez advierte que esa ley perjudica al consumidor o al trabajador, este puede pedir que no se le aplique y que se aplique su derecho propio, por ejemplo la ley del lugar de ejecución del trabajo. Si la ley pactada no es más perjudicial, sino que beneficia, no hay razón para dejarla de lado.

Ejemplo: El derecho del consumidor en Brasil

En el ámbito sudamericano, la ley más protectoria en derecho de consumo es la brasileña. Tiene el código de defensa de los derechos del consumidor, que exige determinado control de calidad y la extensión de las responsabilidades; es mucho más meticuloso y protectorio del consumidor que otras disposiciones. Si en un contrato se eligió el derecho de Brasil y este da más beneficios, ¿con qué fundamento se diría que, por orden público, no corresponde aplicar una ley más favorable para el consumidor? Sería contradictorio.

Por eso se advierte sobre meter en la "bolsa" del orden público cosas que tienen otro fundamento. El fundamento del débil jurídico es buscar la tutela y evitar que elija cosas desfavorables; el orden público, en cambio, habla de los principios fundamentales de la sociedad en general y del ordenamiento en general.

4.3.1 Debate: ¿cuál modalidad protege más?

Los límites de protección a los débiles jurídicos operan, entonces, de dos formas. Una es **prohibir directamente** la elección, que es lo que hace la Argentina. La otra es **permitir la autonomía de la voluntad** en tanto y en cuanto el derecho elegido sea más favorable a los intereses del débil jurídico: se permite, pero hay un control de calidad respecto de la ley elegida, y si perjudica, no se aplica. Se planteó que esta segunda opción lleva a una protección mayor.

La docente observó que se está acostumbrado a que no se puede, sin preguntarse por qué no se puede elegir algo mejor. Una cosa es decir que no se puede elegir porque se protege al débil jurídico, y otra, que se pueda elegir en tanto se vea que la ley lo favorece. Hay normas que van a la prohibición por la prohibición misma.

Frente a la objeción de que quien contrata por necesidad (la compra de algo necesario, un trabajo aceptado "por el pan en la mesa") acepta aunque no le convenga, se respondió que se dicta entonces una ley que lo proteja y que no se puede tocar, con lo que se ahorra tener que evaluar. La docente agregó que es más fácil presumirlo que evaluarlo caso por caso,

que tomarse el trabajo de dejar optar. Y que después, en todo caso, el trabajador puede reclamar que se le aplique la norma que le corresponde, porque la que se eligió no cumple lo que se había pactado (por ejemplo, haber pactado trabajar sin feriados para tomarlos todos juntos y que luego no se los otorguen así).

Los límites dependen de la extensión que se quiera dar a la autonomía de la voluntad. Si se permite elegir en tanto la ley elegida beneficie, la autonomía es mucho más extensa. Decir «no se puede elegir en contrato de consumo, de trabajo y de seguro; no se puede, punto» es un límite liso y llano: ahí no hay autonomía. En cambio, si el Estado permite elegir siempre que la ley elegida beneficie, la autonomía de las partes es más amplia, sujeta después a una evaluación de control de calidad de las leyes elegidas.

Se tienen así tres límites: orden público, norma de policía y protección del débil jurídico.

Table 4.2: Dos modalidades de protección del débil jurídico

	Prohibición de elegir la ley	**Elección permitida si la ley es más favorable**
Cómo funciona	No se puede elegir la ley aplicable. «Punto.»	Se puede elegir, pero hay un «control de calidad» de la ley elegida.
Quién la adopta (según la clase)	República Argentina, en contratos de consumo.	Reglamento de Roma (UE): trabajo, seguro y consumo.
Extensión de la autonomía	Mínima: «límite liso y llano».	Más amplia, sujeta a evaluación de la ley elegida.
Ventaja señalada	Es más fácil: se presume el perjuicio y se «ahorra» evaluar caso por caso.	Si la ley elegida beneficia al débil, no hay razón para sacársela.

4.4 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Quién es el débil jurídico y por qué limita la autonomía?	La parte sin igualdad de negociación: consumidor, trabajador, asegurado. Se limita la autonomía para que no pacte cosas que le sean perjudiciales.
¿Orden público y débil jurídico son lo mismo?	No: son «dos carriles distintos». Algo obligatorio no es necesariamente de orden público. El débil jurídico busca tutela; el orden público protege los principios fundamentales del ordenamiento en general.

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Cómo se protege al débil jurídico?	De dos maneras: prohibiendo elegir la ley (Argentina, consumo) o permitiendo elegirla si es más favorable (Reglamento de Roma). La segunda es más amplia, sujeta a un control de calidad de la ley elegida.
Resumen: la protección del débil jurídico se distingue del orden público y puede operar por prohibición de elegir la ley o por control de la ley más favorable. La primera ofrece una solución más simple; la segunda concede una autonomía más amplia, sujeta a evaluación. Los límites dependen de la extensión que cada Estado quiera dar a la autonomía de la voluntad.	

Chapter 5

Otros límites y momento de la elección de ley

5.1 Moral, buenas costumbres y elementos de extranjería

El primero y principal de estos límites es la **moral y las buenas costumbres**, que entran dentro de los principios del orden público, en la "bolsa general" del orden público.

Otro límite fundamental, y el principal en cuanto a la posibilidad de elegir ley aplicable, es que el contrato tenga **elementos de extranjería**: elementos que vinculen distintos sistemas jurídicos.

Ejemplo: El contrato sin ningún elemento extranjero

El contrato se celebra entre dos argentinos, comprador y vendedor, en la ciudad de Buenos Aires; el lugar de cumplimiento, la entrega de la mercadería, es en Corrientes, República Argentina; el garante es la madre del comprador, que es argentina; se contrata una compañía de seguro argentina. ¿Para qué aplicar el derecho de Rusia? Si el contrato tiene todos los elementos reunidos o conectados con un único ordenamiento jurídico, no se puede elegir derecho extranjero: se aplica la normativa nacional de ese Estado.

Para poder hacer autonomía conflictual, el contrato debe tener estos elementos de extranjería: debe ser internacional o, en el caso de la clase, regional, es decir, vincular de alguna manera a los países del Mercosur. Por ejemplo, el domicilio del comprador está en un Estado y el del vendedor en otro, aunque el contrato se haya celebrado y ejecutado en el mismo: hay un elemento de extranjería.

Importante

Sin elementos de extranjería no hay autonomía conflictual: si todos los elementos del contrato están conectados con un único ordenamiento, se aplica la normativa

nacional de ese Estado. Basta con un elemento de extranjería, por ejemplo el domicilio de cada parte en un Estado distinto.

5.2 Momento de la elección: autonomía amplia o cerrada

Otro límite es el tiempo en el cual se puede elegir la ley aplicable. Una **autonomía amplia** permitiría elegir la ley aplicable al contrato en cualquier momento de la relación jurídica, porque el contrato es el acuerdo de voluntades de dos partes. Si ambas están de acuerdo en cambiar la ley aplicable y no perjudican a nadie —por ejemplo, aplicar la ley argentina en lugar de la de Uruguay—, lo deciden ellas y no molestan a nadie; no hay cuestiones de orden público en juego.

Una **autonomía más cerrada** permitiría hacer uso de la autonomía de la voluntad solo al momento de celebrar el contrato. Una vez celebrado, queda establecida la ley aplicable, ya sea porque las partes eligieron o porque no eligieron; si no eligieron, lo determina la norma de conflicto. Pero la ley aplicable queda fijada y no se puede modificar después.

Table 5.1: Autonomía amplia y autonomía cerrada en el tiempo

	Autonomía amplia	**Autonomía cerrada**
Cuándo se puede elegir o cambiar la ley	En cualquier momento de la relación jurídica.	Solo al celebrar el contrato.
Si no se eligió	Pueden elegirla o cambiarla después.	Rige lo que diga la norma de conflicto; queda fijada y no se modifica.
Razón	El contrato es acuerdo de voluntades: si ambas partes están de acuerdo y no perjudican a nadie, no hay problema.	Seguridad: la ley aplicable queda determinada desde la celebración.

5.2.1 Condiciones lógicas para una autonomía amplia

Para que una autonomía amplia sea lógica, se señalaron condiciones. La primera es que **no afecte derechos de terceros**: la nueva ley no puede afectarlos. Por ejemplo, si el garante tenía una determinada responsabilidad limitada a cierta extensión y, al cambiar la ley aplicable, pasa a responder más, se afecta un derecho por una relación pactada entre comprador y vendedor. El derecho elegido no puede afectar los intereses de terceros ni la validez del contrato: si según la nueva ley el contrato resultara nulo, no tendría sentido. No pueden alterarse ni la validez formal del contrato ni los derechos adquiridos por terceros.

Respecto de hasta cuándo puede hacerse el cambio, se respondió que **hasta el cumplimiento**: una vez cumplido el contrato, ya no se puede. Ante la pregunta de si podría elegirse la ley aplicable durante el juicio, un alumno respondió que durante el juicio no, pero que antes de ir a juicio sí se puede pactar, como otra autonomía de la voluntad.

Importante

La nueva ley elegida no puede afectar (1) los derechos adquiridos por terceros ni (2) la validez formal del contrato. En el debate, los alumnos ubicaron el límite temporal en el cumplimiento del contrato: una vez cumplido, ya no se puede cambiar la ley.

5.3 El Reglamento de Roma y la elección tácita de la ley

El Reglamento de Roma sobre obligaciones contractuales permite la autonomía y el cambio de ley aplicable **en cualquier momento, aun durante el proceso**, y tanto de forma escrita como de forma tácita. Es decir, se puede modificar, durante el proceso y de común acuerdo con la otra parte, la ley que el juez debía aplicar, y hacerlo de manera tácita.

Se planteó que esto generaría inseguridad ("a nosotros nos daría pánico"), y que corresponde al juez evitar que se viole la seguridad jurídica entre las partes; también se preguntó cómo se sabe que hubo acuerdo tácito. La docente respondió que hay elección tácita cuando una parte empieza a invocar derecho extranjero de un tercer Estado y la otra parte contesta sobre la misma normativa: eso es lo que Roma define como elección tácita.

Definición: Elección tácita de la ley (Reglamento de Roma)

Según lo expuesto en clase, la ley aplicable puede elegirse o cambiarse en cualquier momento —antes, durante o después de surgido el conflicto, incluso durante el juicio— y de forma expresa o tácita. Hay elección tácita cuando una parte invoca el derecho de un Estado y la otra contesta sobre la misma normativa.

5.3.1 Objeción planteada

Un alumno objetó que, si la parte invoca por escrito en un expediente judicial determinada norma de un código extranjero, firmada por ella y por su abogado, y la otra contesta por escrito invocando otra norma del mismo código, "lo estamos poniendo por escrito: ¿qué tácito?". La docente respondió que ese es precisamente el ejemplo que da Roma cuando dice que se puede hacer en cualquier momento, antes, durante o después de surgido el conflicto, aun durante el juicio, y de forma expresa o tácita: es decir, qué amplia es la autonomía de la voluntad.

El alumno insistió en que, cuando se define lo tácito como el caso en que un derecho es invocado por una parte y la otra contesta, se interpreta que la cláusula escrita de ley

aplicable pactada en el contrato fue cambiada de esa forma. A su juicio no sería una forma tácita, sino un **acuerdo no simultáneo**: uno lo hizo en un momento y el otro confirmó la elección de ese derecho en otro; es expreso y no tácito. Sería más tácito, por ejemplo, enviar una orden de compra sin firmar.

5.4 Cuadro Cornell

Preguntas / palabras clave	**Notas / respuestas**
¿Qué otros límites mencionó la docente?	La moral y las buenas costumbres (dentro del orden público) y la necesidad de elementos de extranjería: sin ellos no se puede elegir derecho extranjero.
¿Cuándo se puede elegir o cambiar la ley aplicable?	Autonomía amplia: en cualquier momento. Autonomía cerrada: solo al celebrar el contrato. Si se cambia, no puede afectar derechos de terceros ni la validez formal del contrato; los alumnos señalaron como límite el cumplimiento.
¿Qué dice el Reglamento de Roma sobre el momento y la forma de la elección?	Permite elegir o cambiar la ley en cualquier momento, incluso durante el proceso, de forma expresa o tácita. Hay elección tácita cuando una parte invoca el derecho de un Estado y la otra contesta sobre la misma normativa.
¿Qué objeción se planteó a la elección tácita?	Que, si lo invocado consta por escrito en el expediente, el acuerdo es expreso, aunque no simultáneo. Más tácito sería, por ejemplo, mandar una orden de compra sin firmar.
Resumen: para elegir ley el contrato debe tener elementos de extranjería, y la moral y las buenas costumbres integran el orden público. Respecto del momento, la autonomía puede ser amplia (en cualquier momento) o cerrada (solo al celebrar), con límites frente a terceros y la validez del contrato. El Reglamento de Roma admite la elección en cualquier momento, incluso durante el proceso, expresa o tácita. La libertad de las partes es real pero nunca absoluta: cada Estado decide cuánta le concede y dónde pone el freno.	